

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL II (ART. 216-A E 216-B)

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

Dando continuidade aos crimes contra a dignidade sexual, vamos estudar agora o delito de assédio sexual (art. 216-A, do Código Penal).

Assédio sexual

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos

Parágrafo único.

§ 2º o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.

Apesar de esse delito ter Parágrafo único, não há qualquer redação nele, uma vez que este foi vetado. Assim, no crime de assédio sexual, há apenas o § 2º.

A palavra “Constranger”, no crime de assédio sexual, não será como no crime de estupro, que é um constrangimento mediante violência ou grave ameaça. No assédio sexual, o constrangimento traz um sentido de importunação, de molestar, de intimidar a vítima. O agente faz isso sendo um superior hierárquico ou alguém que tem uma ascendência inerente à cargo, emprego ou função, em relação ao seu subordinado.

Então, essa pessoa que está hierarquicamente superior ou possui um cargo de chefia, seja na administração pública, seja em empresas privadas, valendo-se dessa condição de superior hierárquico ou de ascendência inerente à função, cargo, ou emprego, constrange a vítima a praticar com ela atos sexuais, atos libidinosos.

Esse é um delito que não necessariamente terá uma ameaça ou uma promessa de promoção, um oferecimento de promoção, mas é comum que esteja acompanhado dessas situações. O constrangimento não é apenas um flerte, o que não é proibido em âmbito empresarial ou no âmbito da administração pública. Não há crime nessa conduta do flerte, o crime é o constrangimento. Isto é, o crime é importunar uma pessoa valendo-se da sua condição de superior hierárquico.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Eventualmente, esse delito vem acompanhado de uma ameaça, ou seja, o chefe ou superior hierárquico deixa implícito à vítima que, caso ela não mantenha com ele relações sexuais, ela será demitida, ou desfavorecida no seu emprego. Além de uma ameaça, esse crime também pode vir acompanhado de uma promessa. Pode-se prometer que, ao manter relações sexuais com o seu superior, a vítima terá uma promoção no trabalho com maior remuneração. Isso não precisa estar explícito, podendo ser algo tácito, algo que seja captado nas entrelinhas.

Portanto, o flerte, o namoro ou casamento entre pessoas que trabalham juntas não é proibido. O que é proibido é o constrangimento, a intimidação ou a perturbação para que haja um tipo de relação sexual, valendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerente à função, emprego ou cargo.

ATENÇÃO

O favorecimento sexual, ao qual o art. 216-A faz referência, pode ser qualquer coisa, inclusive, um beijo.

Qual a diferença entre superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função? Se fala em hierarquia no âmbito da administração pública. Então, só existe superior hierárquico no âmbito da administração pública. Já ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função ocorre no âmbito das pessoas jurídicas privadas.



Cuidado com o § 2º!

Quando esse parágrafo estabelece que a pena será aumentada em até um terço, ele não traz um quantitativo mínimo de aumento de pena. Entretanto, no Código Penal, e no direito penal como um todo, não existe aumento de pena menor do que um sexto. Então, a doutrina entende que, na verdade, esse aumento de pena, como é até um terço, pode ser de um sexto até um terço.

O aumento mínimo que o juiz pode aplicar no caso concreto é de um sexto da pena, se a vítima é menor de 18 anos. Vamos ver um exemplo: um adolescente de 13 anos de idade

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

trabalha em uma fazenda. Então, valendo-se da sua condição de empregador o dono da fazenda passa a constranger aquele menor para que haja uma conjunção carnal, ou algum tipo de favorecimento sexual. Que crime vamos ter nesse exemplo?

Não é abuso sexual. Quando se estabelece que haverá um aumento de pena se a vítima for menor do que 18 anos é quando a vítima tiver entre 14 e 18 anos. Se a vítima for menor de 14 anos a conduta de obter uma vantagem ou favorecimento sexual com um menor de 14 anos recai no art. 217-A, que é o crime de estupro de vulnerável.

A pena do assédio sexual é de detenção de um a dois anos. Logo, esse é um crime de menor potencial ofensivo. Contudo, se houver o aumento de pena, ainda que apenas de um sexto, repare que a pena mínima deixa de ser de um ano e a pena máxima passa a ser mais do que dois anos. Assim, esse crime de menor potencial ofensivo, com a causa de aumento do § 2º, passa a ser um crime de elevado potencial ofensivo. Ele seria de médio potencial ofensivo se a pena mínima fosse de, no máximo, um ano, mas, com o aumento de pena, o menor tempo possível seria de um ano.

Classificação:

1) Somente na modalidade dolosa

O crime de assédio sexual somente pode ser praticado na modalidade dolosa. Então, imagine que o chefe gosta muito de sua subordinada e quer manter com ela relações sexuais. Assim, ele passa a importuná-la, mas não com o dolo, com a intenção de constrangimento. Ele simplesmente não percebe que está sendo inoportuno e acaba importunando essa pessoa.

Nesse caso, não houve dolo, não houve dolo de constranger, valendo-se da sua condição de superior hierárquico, de ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, não haveria crime nessa situação. É necessário que haja o dolo.

ANOTAÇÕES

2) Crime formal (de resultado cortado)

Trata-se de um crime formal, de resultado cortado. Então, independentemente da efetiva relação sexual, ou favorecimento sexual, que seja prestado ao autor, o crime estará consumado. O crime se consuma com o constrangimento, e não com o ato sexual, que é simplesmente um pós-fato impunível.

3) Tentativa é cabível

Pode-se tentar constranger, mas não conseguir o constrangimento.

4) APPI

É um crime de ação penal pública incondicionada.

5) Crimes instantâneo, mas parte da doutrina entende ser habitual

É um crime instantâneo, mas parte da doutrina entende ser habitual. Parte da doutrina afirma que esse crime de assédio sexual só vai se consumir se houver condutas reiteradas. Uma simples única conduta de constrangimento à vítima não configuraria o assédio sexual. Seria necessária uma prática reiterada de atos para que haja esse constrangimento.

Contudo, essa é uma parcela minoritária, já que a maior parte da doutrina entende que este é um crime instantâneo. Isto é, o simples ato e constrangimento, valendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao emprego, cargo ou função seria suficiente para consumir o delito.

6) Crime de menor potencial ofensivo

Em regra, é um crime de menor potencial ofensivo.



10m

ANOTAÇÕES

7) Crime bipróprio

Isso significa que, em relação ao sujeito ativo, será um crime próprio, ou seja, somente pode ser praticado por aquele que é superior hierárquico ou tem ascendência inerente a cargo, emprego ou função; e, em relação ao sujeito passivo, também será um crime próprio, porque somente pode ser sujeito passivo desse delito aquele que seja inferior hierárquico, aquele que seja subordinado em um emprego, cargo ou função.

Por exemplo, existe um chefe de uma repartição pública e a sua subordinada, inferior hierárquica. Ela começa a constranger o seu chefe para obter um favorecimento sexual. Nesse caso, não houve crime de assédio sexual. Ela pode até vir a responder por uma contravenção penal que é a perturbação da tranquilidade, mas não será o crime de assédio sexual.

O assédio sexual tem a elementar que somente pode ser praticado por um superior hierárquico em relação ao subordinado, alguém que tenha ascendência inerente a cargo, emprego ou função em relação ao seu subordinado.

ATENÇÃO

Esse crime pode ser praticado por homem ou mulher e a vítima também pode ser homem ou mulher. O crime de assédio pode existir, inclusive, em relações homossexuais, não há qualquer tipo de limitação à orientação sexual no que concerne a esse crime.

É possível o assédio sexual de professor com relação ao aluno?

ATENÇÃO

Atenção a essa pergunta, já que ocorreu uma mudança no entendimento jurisprudencial. Sobre essa questão, sempre existiram dois posicionamentos. Um posicionamento acredita que é sim possível haver esse assédio sexual de um professor em relação ao aluno. Já o outro posicionamento afirmava que não, porque, apesar de o professor ter algum tipo de poder em relação ao aluno, não haveria hierarquia, nem qualquer tipo de ascendência inerente a cargo, emprego ou função, do professor em relação aos alunos. Então, não estaria configurado o tipo penal do assédio sexual. Esse era o entendimento predominante, mas não é mais.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

1ª Corrente: não. Porque não há relação de emprego ou função entre o professor e o aluno, e sim entre o professor e a faculdade.

2ª Corrente: sim, é possível. Porque, apesar de não ser superior hierárquico, há um domínio do professor sobre o aluno.

Essa primeira corrente não era pacífica, mas era a que, em regra, deveria ser adotada nos concursos públicos. Contudo, isso mudou com o entendimento do STJ. Veja a seguir.

Qual corrente prevalece?

Doutrina: primeira corrente, no sentido de não caracterizar assédio sexual!

Para a doutrina, o que prevalece é a primeira corrente, no sentido de não caracterizar assédio sexual. A doutrina ainda entende que não há relação de subordinação entre professor e aluno. Então, a maior parte da doutrina segue a primeira corrente. Esse era o entendimento predominante, mas depois de um julgado do STJ de 2019, houve uma mudança no entendimento da jurisprudência.

Jurisprudência: segunda corrente!

O crime de assédio sexual pode ser caracterizado entre professor e aluno. O crime de assédio sexual (art. 216-A do CP) é geralmente associado à superioridade hierárquica em relações de emprego, no entanto pode também ser caracterizado no caso de constrangimento cometido por professores contra alunos. (...) Caso concreto: o réu, ao conversar com uma aluna adolescente em sala de aula sobre suas notas, teria afirmado que ela precisava de dois pontos para alcançar a média necessária e, nesse momento, teria se aproximado dela e tocado sua barriga e seus seios. (STJ. REsp 1.759.135/SP, julgado em 13/08/2019 (Info 658)).

Portanto, o STJ entendeu que essa conduta é sim assédio sexual.

ANOTAÇÕES



O PULO DO GATO

Nas provas de concurso, as bancas devem trazer uma introdução do tipo “De acordo com o STJ” ou “De acordo com jurisprudência, é possível o assédio sexual entre professores e alunos”. Nesses casos, marque correto. Entretanto, mesmo que a banca não utilize essa introdução, o posicionamento mais seguro a se tomar ainda é seguir o entendimento do STJ, porque a jurisprudência tem muita força. Já em uma prova oral ou discursiva, trate das duas correntes.



15m

É possível o assédio sexual de líderes religiosos (padres, pastores etc.) **com relação aos fiéis?**

Não, porque não há relação de emprego ou função entre o líder religioso e o(a) fiel. Assim, exceto no caso de professor e aluno, segue-se o entendimento da doutrina.

Obs.: é possível haver, todavia, violação sexual mediante fraude (art. 215, CP) no caso em que o líder religioso afirma ter recebido uma revelação de que deve praticar com o(a) fiel atos libidinosos.

Essa é uma situação distinta. Mediante fraude, o líder religioso afirma para o fiel, ou a fiel, que recebeu uma revelação ou uma visão de que eles têm que manter conjunção carnal. Neste caso, houve uma violação sexual mediante fraude, o que recai em outro tipo penal, no art. 215, do Código Penal, e não no assédio sexual.



DIRETO DO CONCURSO

1. (QUESTÃO INÉDITA/2020) João trabalha no Ministério da Economia e possui a mesma posição hierárquica que Maria. Em razão de considera-la atraente, passa a constrange-la frequentemente a praticar com ele atos sexuais. Apesar de todas as negativas, João continua a assedia-la, de forma que ela já não mais suporta essa situação. Nesse caso, João praticou assédio sexual?

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Não há que se falar no delito de assédio sexual quando o responsável pelo constrangimento estiver na mesma posição hierárquica, ou inferior, que a suposta vítima. Então, em que pese ele estar constrangendo, assediando, ela pode buscar outros meios legais. Poderia até mesmo configurar uma contravenção, dependendo do que ele venha a fazer, ou até mesmo uma importunação sexual, art. 215-A, mas não vai configurar assédio sexual.

Registro não autorizado da intimidade sexual

CAPÍTULO I-A – DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL (LEI N. 13.772, DE 2018) REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL

Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: (Incluído pela Lei n. 13.772, de 2018)

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.

A Lei n. 13.772, de 2018, foi publicada e entrou em vigor no dia 20 de dezembro de 2018. Essa lei surge como uma *novatio legis* incriminadora, que também acaba sendo uma *novatio legis in pejus*. Logo, esse delito não se aplica a condutas praticadas anteriores a 20 de dezembro de 2018.

Se alguém, no dia 15 de dezembro de 2018, pratica essa conduta, não há que se falar nesse delito. Esse delito só passa a existir no dia 20 de dezembro de 2018.

Esse delito é importantíssimo e tende a ser cobrado nas provas de concurso com muita frequência.

Além disso, repare que o tipo penal traz vários verbos: produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio. Assim, como se afirma que é por qualquer meio, pode-se registrar uma cena de nudez, por exemplo, por meio de uma pintura. Essa situação configuraria esse delito.

ANOTAÇÕES

Um exemplo desse delito é quando uma pessoa está na sacada do prédio e vê uma moça, no prédio ao lado, trocando de roupa. Essa pessoa pega uma câmera filmadora, dá um zoom, e filma essa moça trocando de roupa. Nesse caso, mesmo que a pessoa não divulgue as imagens, haverá o crime. Se a pessoa divulgar as imagens, haverá um outro crime, que veremos mais à frente. O simples fato de se filmar ou registrar uma cena de nudez de caráter íntimo e privado, sem autorização do participante faz com que o crime esteja consumado.

Outro exemplo é quando um namorado sabe que praticará atos sexuais com sua namorada e coloca uma câmera filmadora, ou fotográfica, ou webcam, ligada filmando esse ato sexual. Ele está filmando um ato sexual, próprio. Em tese, ele poderia fazer isso. Entretanto, sem a autorização da namorada, o crime estará configurado.

Então, esse é um delito importantíssimo e que tem muita relação com a tecnologia e com os dias atuais. Também está relacionado com as questões de pornografia e vazamento de filmagens que não foram autorizadas pela pessoa. A divulgação é outro crime que ainda veremos mais à frente.

Sobre ser “de caráter íntimo e privado”, houve um caso de uma modelo que estava mantendo algum ato libidinoso ou relação carnal na praia com seu namorado, dentro do mar. Alguém filmou e divulgou as imagens. O simples fato de filmar, ou fotografar, um casal que se encontra na praia, que se encontra em praça pública, que se encontra na praia, configuraria esse crime? Não.

O simples ato de filmar não configura, porque para que haja o crime de registro não autorizado da intimidade sexual, precisa-se que este ato sexual, essa nudez, esse ato libidinoso, tenha caráter íntimo e privado. Sobre alguém que pratica um ato sexual em uma praça pública ou em uma praia pública, não há que se falar nesse delito. O ato poderia ser de caráter íntimo, mas era de caráter público, não configurando o crime. Já a divulgação é outra história.

Além disso, esse é um crime de menor potencial ofensivo. No parágrafo único, fica claro que haverá essa conduta ainda que não se divulgue. Mesmo que alguém pegue apenas o rosto da pessoa e faça uma montagem dela no corpo nu de outra, isso já configurará o crime, inclusive, se a imagem não for divulgada.



25m

ANOTAÇÕES

Características

1) Intimidade sexual: bem jurídico

O bem jurídico protegido por esse crime é a intimidade sexual.

2) Dolo

É um crime que somente pode ser praticado mediante dolo. É o dolo de registrar uma atividade sexual não autorizada. Se por acaso uma pessoa tem câmeras de segurança em uma residência e essa câmera acaba flagrando um ato sexual praticado pelo vizinho devido a sua posição, isso não configura delito. Isto, porque, em que pese a câmera de segurança ter registrado esse ato sexual, que era um ato íntimo, de caráter privado, sem autorização dos participantes, não houve dolo.

3) Tentativa

A tentativa é possível. Pode-se tentar registrar e não conseguir.

4) APPI

É um crime de ação penal pública incondicionada. Não depende de representação da vítima e não depende de requisição ou queixa-crime.

5) Tipo misto alternativo

Trata-se de um tipo misto alternativo. Isso significa que há vários verbos no tipo penal: produzir, fotografar, filmar ou registrar.

Por exemplo, se em um mesmo contexto fático, uma pessoa fotografar e filmar um ato sexual de duas ou mais pessoas, sem que elas soubessem, ela responderá somente por um crime, porque é um tipo misto alternativo. Assim, se vários desses verbos vierem a ser praticados em um mesmo contexto fático, haverá somente um delito.

ANOTAÇÕES

6) Crime bicomum

Um crime bicomum é um crime que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Ao contrário do que vimos no assédio sexual, que era um crime biproprio, este crime de registro não autorizado da intimidade sexual é um crime bicomum.

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo também. Entretanto, faz-se necessário fazer uma ressalva, principalmente, para os concursos que cobram o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se por acaso essa conduta de registro não autorizado da intimidade sexual, ou de uma cena de nudez, tiver como sujeito passivo uma criança ou adolescente, alguém menor de 18 anos, recairá em uma conduta do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Então, repare que este crime só pode ter como sujeito passivo um maior de 18 anos. Em que pese ser um crime bicomum, o sujeito passivo tem que ser maior de 18 anos. Se for menor do que 18 anos, recai sobre o art. 240, do Estatuto da Criança e do Adolescente.



Estatuto da Criança e do Adolescente

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (...)

Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia

CÓDIGO PENAL

Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia (Incluído pela Lei n. 13.718, de 2018)

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.

ANOTAÇÕES

Uma coisa é registrar a cena de sexo ou a cena de nudez, outra coisa é divulgar essa cena. São cinco situações nas quais há o crime de divulgação de cena de estupro. Nesse crime, a pena é bem mais grave: reclusão de um a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Ainda não é um ponto pacífico, mas a doutrina entende que, havendo a divulgação de uma cena de sexo, que foi registrada pelo agente, ele responderia por dois crimes. Isto é, sempre que o agente registrar e divulgar uma cena de sexo, ele responderá pelo art. 216-B e pelo art. 218-C.

GABARITO

1. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
